

第8問

甲は、Aから100万円を渡され、「Bから金を借りているので、これをBに返しに行って欲しい。Bは利子が付いて200万円だなどと言うかもしれないが、ひとまず、これを置いてきてくれればいいから。」などと依頼された。甲は、金額について折り合いがついていないようであることや、Bが血気盛んな性格であることから、自分が行ったとしても、けんか沙汰になるかもしれないと考え、気が進まなかったが、Aには日頃から面倒を見てもらっていたため、これを了承した。

甲は、万が一Bに襲われたときに備えて、護身用の伸張式の警棒（アルミ製、長さ約21センチメートル）を携帯することにした。甲がB方に着くと、Bは、応接室へと甲を通した。甲が、「Aさんから100万円を預かってきたので、受け取って欲しい。」と伝えたところ、Bは、突如として憤慨し、「これっぽちの金を受け取れっていうのか。Aの前にお前を殺してやろうか。」などと叫び、テーブルに置かれたガラス製の灰皿をつかみ、甲の目の前で頭上まで持ち上げた。甲は、とっさに身の危険を感じ、これを避けようとするとともに、A B間のトラブルとは無関係の甲に対して怒号するBに腹を立てたため、用意していた警棒を取り出し、Bの顔面を殴打した。Bは、その場に倒れこみ、頭部を強く打ち、全治約1か月を要する頭頂部打撲挫創の傷害を負った。

甲の罪責について、論じなさい（特別法違反の点を除く。）。

1 甲の行為が傷害罪（204）の構成要件に該当することを確認し、正当防衛の成否を検討することになるが、本問では、①Bは灰皿を頭上まで持ち上げたにとどまり、攻撃を開始していないとも思えること、②甲がBによる侵害を予期していたこと、③甲がBに腹を立てて攻撃していること、④警棒で頭部を強く打ったことが問題となる。①②は急迫性の問題、③は防衛の意思の問題であり、④は行為の相当性の問題である。

2 ①につき、「急迫不正の侵害」とは、「法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていること」（最判昭46.11.16）をいうところ、侵害の開始時期（**論点** 侵害の開始時期と終了時期）については、実行の着手まで至る必要はないが、密着した予備行為に至っていなければならないと解されている。

総合 60 頁 論証 16 頁

本問では、Bが「殺してやろうか。」などと叫びながら、ガラス製の灰皿を甲の目の前で頭上まで持ち上げているため、少なくとも密着した予備行為には至っているといえることから、この要件は満たす。

3 ②は、いわゆる侵害の予期と急迫性の要件に関わる問題である（**論点** 行為者の主観面と急迫性 **論** 司H18,R4,IBH6-1,H14-1）。判例（最決昭52.7.21）は、「当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではない」が、「その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさない」としていた。

総合 62 頁 論証 17 頁

もっとも、近時判例は、「刑法36条は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものである。したがって、行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合、侵害の急迫性の要件については、侵害を予期していたことから、直ちにこれが失われると解すべきではなく（最高裁昭和……46年11月16日……判決……参照）、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には、事案に応じ、行為者と相手方との従前の関係、予期された侵害の内容、侵害の予期の程度、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性、侵害場所にとどまる相当性、対抗行為の準備の状況（特に、凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等）、実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同、行為者が侵害に臨んだ状況及びその際^{（1）}の意思内容等を考慮し、行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき（最高裁昭和……52年7月21日……決定……参照）など、前記のような刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には、侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。」（下線部は担当者）として、昭和52年決定によって打ち立てられた積極的加害意思論を包摂する、新たな判断枠組みを定立した（最決平29.4.26【百選I 23】）。

本問では、甲は、けんか沙汰になるかもしれないと考え、護身用の伸張式の警棒（アルミ製、長さ約21センチメートル）を携帯しているものの、万が一Bに襲われたときに備えているにすぎない。また、Bのもとに出向いたのは、日ごろから面倒を見てもらっているAからBに対して借金の返済を頼まれたからであり、侵害場所に出向く必要性もあった。

したがって、「刑法36条の趣旨に照らし許容される」（平成29年決定）から、急迫性の要件は満たす。

- 4 ③防衛の意思については、判例（最判昭46.11.16、最判昭50.11.28【百選I24】、最判昭60.9.12）はこれを必要とするものの、攻撃の意図が並存していてもよいとする（**論点** 防衛の意思  司H18,H23,IH6-1,H21-1）。

 総合 69 頁  論証 20 頁

本問では、身の危険から避けようとする意思も認められるため、防衛の意思も問題なく認められる。

- 5 最後に、④「やむを得ずにした」であるが（**論点** 「やむを得ずにした行為」（36I）（防衛行為の相当性）  司H18,H23,H27,H29,R4,予H26,IH21-1）、武器対等の原則を念頭に置きつつも、攻撃者と防衛行為者の性別、年齢、力量等をも考慮して社会的に許容される行為と認められる行為か否かで決するなどと言われている。

 総合 72 頁  論証 21 頁

Bの攻撃は、ガラス製の灰皿を用いたものであり、頭上まで持ち上げたことからすれば、これを振り下ろして、甲の頭部等、枢要部に向かった攻撃であると考えられる。そのため、甲の攻撃も、危険なものであるものの、社会的に許容される行為であるとみるべきだろう。

答案構成

1 傷害罪（204）の構成要件該当性あり

↓

2 正当防衛の成否

↓

「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいうから、法益侵害の危険が具体的に切迫していることが必要

↓

あてはめ

↓

侵害の予期がある場合にも「急迫」性の要件を満たすか

↓

行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときなど、36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には、侵害の急迫性の要件を充たさない

↓

あてはめ

↓

「急迫不正の侵害」あり

↓

「防衛するため」

↓

防衛の意思は必要だが、その内容は侵害の認識と侵害に対応する意思があれば足りる（攻撃の意思が併存していてもよい）

↓

あてはめ

↓

「やむを得ずにした行為」

↓

防衛手段としての相当性を意味する

↓

武器対等の原則を基本としつつも、攻撃者と防衛行為者の性別、年齢、力量等をも考慮して、社会通念上許容される行為か否か判断する

↓

あてはめ

↓

3 正当防衛が成立するため、不可罰となる

1 甲が警棒でBの顔面を殴打し、全治約1か月を要する頭頂部打撲挫創
2 の傷害を負わせた行為は、人の生理的機能を害するものであるから、
3 「人の身体を傷害した」といえ、傷害罪（204条）の構成要件に該当
4 する。

5 2 もっとも、甲は、Bがテーブルに置かれたガラス製の灰皿をつかみ、
6 頭上まで持ち上げたことに対応して、上記行為をしている（以下「本件
7 行為」という。）。そのため、正当防衛（36条1項）が成立しない
8 か。

9 (1) まず、「急迫」（36条1項）とは法益の侵害が現に存在している
10 か、又は間近に押し迫っていることをいうから、侵害の急迫性が認め
11 られるためには、法益侵害の危険が具体的に切迫していることが必要
12 である。

13 確かに、Bは、テーブルに置かれたガラス製の灰皿をつかみ、頭上
14 まで持ち上げたにすぎず、まだ攻撃を開始していない。しかし、これ
15 を振り下ろせば、甲の身体に危害を加えることができる状態であるか
16 ら、甲の身体を安全を害する危険が具体的に切迫しているといえる。

17 したがって、甲の身体を安全という「権利」に対する「急迫不正の
18 侵害」があるといえそうである。

19 もっとも、甲は、けんか沙汰になるかもしれないと思い、警棒を携
20 帯している。このように侵害を予期している場合でも「急迫」性の要
21 件を満たすか。

22 36条は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法

1

1 的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私
2 人による対抗行為を例外的に許容したものである。

3 したがって、行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合、
4 侵害の急迫性の要件については、侵害を予期していたことから、直ち
5 にこれが失われると解すべきではなく、対抗行為に先行する事情を含
6 めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には、事案
7 に応じ、行為者と相手方との従前の関係、予期された侵害の内容、侵
8 害の予期の程度、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性、侵害
9 場所にとどまる相当性、対抗行為の準備の状況（特に、凶器の準備の
10 有無や準備した凶器の性状等）、実際の侵害行為の内容と予期された
11 侵害との異同、行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意味内容等を
12 考慮し、行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為
13 をする意思で侵害に臨んだときなど、前記のような36条の趣旨に照
14 らし許容されるものとはいえない場合には、侵害の急迫性の要件を充
15 たさないものというべきである。

16 本問では、甲は、けんか沙汰になるかもしれないと考え、侵害を予
17 期しつつ、護身用の伸張式の警棒を携帯しているものの、万が一Bに
18 襲われたときに備えているにすぎない。また、Bのもとに出向いたの
19 は、日ごろから面倒を見てもらっているAからBに対して借金の返済
20 を頼まれたからであり、侵害場所に出向く必要性もあった。

21 このような先行事情を含めた本件行為全般の状況に照らすと、甲の
22 本件行為は、36条の趣旨に照らし許容されるものと認められ、侵害

2

の急迫性の要件を充たす。

したがって、「急迫」性の要件を満たすから、「急迫不正の侵害」があるといえる。

(2)ア 次に、甲は、とっさに身の危険を感じるとともに、A B間のトラブルとは無関係の甲に対して怒号するBに腹を立てたため、上記行為に及んでいる。そのため、防衛の意思を欠き、「防衛するため」とはいえないのではないか。

イ 防衛の意思の要否につき争いあるも、行為の社会的相当性を判断するためには行為者の主観面も考慮に入れるべきであるし、条文上も「防衛するため」とされているから、これを必要と解すべきである。

ウ それでは、防衛の意思をどのような内容と解すべきか。

防衛行為は事の性質上、興奮・逆上して反射的になされることが多く、積極的な防衛の動機を要求するべきではない。そうだとすれば、防衛行為時の意思内容としては、侵害の認識と侵害に対応する意思があれば足り、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、必ずしも防衛の意思を欠くものではないと解すべきである。

本問では、甲は、Bに腹を立てて攻撃をしているため、攻撃の意思を有しているものの、Bの攻撃に対して、とっさに身の危険を感じて対応しており、侵害の認識と侵害に対応する意思がある。

したがって、防衛の意思が認められる。

3

よって、「防衛するため」といえる。

(3) 最後に、「やむを得ずにした行為」については、正当防衛の場合、防衛者とその相手方とは「正対不正」の関係にあるから、必ずしも防衛行為が唯一の侵害を回避する方法であることは要求されないし、厳格な法益の権衡も要求されない。

したがって、反撃行為自体が防衛手段としての相当性を満たしていれば「やむを得ずにした行為」といってよい。具体的には、武器対等の原則を基本としつつも、攻撃者と防衛行為者の性別、年齢、力量等をも考慮して、社会通念上許容される行為か否か判断する。

本問では、甲の反撃は、アルミ製の長さ約21センチメートルの警棒という危険な道具を用いて、頭部という人間の枢要部を殴打している。もっとも、Bの攻撃は、ガラス製の灰皿を振り下ろすというものであり、当たり所が悪ければ、重大な結果が生じ得る危険な行為であるから、武器対等の原則を満たすものである。

そのため、他に特段の事情がない限り、社会通念上許容される行為であるといえる。

本問では特段の事情は認められないから、防衛手段としての相当性を満たしており、「やむを得ずにした行為」といえる。

3 以上より、甲の行為に正当防衛が成立するため、甲は不可罰である。

以上

4